Ngày 6 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Người nhận: Ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đồng kính gửi: Ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ông Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Về việc: Góp ý đối với dự thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều và quy định việc lựa chọn nhà đầu tư của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Kính thưa Bộ trưởng,

Trước hết, chúng tôi, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam ("JCCI") và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản ("JBIC") chân thành cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo của Bộ trưởng cho cuộc hội đàm giữa Ngài Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tại Hội nghị cấp cao song phương vào ngày 19/10/2020, trong đó Thủ tướng Suga thể hiện rõ mong muốn Việt Nam sẽ thực hiện đầy đủ, phù hợp Luật số 64/2020/QH14 về Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ("Luật PPP").

Việc ban hành Luật PPP là một dấu mốc quan trọng trong chính sách về đầu tư theo phương thức đối tác công tư ở Việt Nam, thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy đầu tư theo phương thức này và đưa khuôn khổ PPP tiếp cận các tiêu chuẩn hiện đại quốc tế. Chúng tôi hiểu rằng, trong bước tiếp theo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khác sẽ phối hợp ban hành các văn bản hướng dẫn để thực hiện hiệu quả chính sách mới. Vào ngày 18/10/2020, VCCI đã chia sẻ với JCCI Bản dịch tiếng Anh của (i) dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PPP ("Nghị định hướng dẫn") và (ii) dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PPP về lựa chọn nhà đầu tư ("Nghị định về lựa chọn nhà đầu tư") đang được lấy ý kiến công khai (gọi chung là "Các Nghị định").

Nhân cơ hội này và để bổ sung vào các ý kiến trước đó mà chúng tôi cũng đính kèm trong thư này để quý vị tham khảo, chúng tôi mong muốn đóng góp xây dựng thành công thị trường PPP khả thi, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Chúng tôi rất vinh dự được phối hợp

chặt chẽ với Bộ KH&ĐT trong quá trình soạn thảo Luật PPP và mong muốn chia sẻ một số ý kiến góp ý của chúng tôi để Chính phủ xem xét.

Liên quan đến dự thảo các Nghị định, chúng tôi cho rằng các Nghị định này cần được ban hành hiệu quả để hỗ trợ thực hiện Luật PPP, cho phép các nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức tài chính nước ngoài yên tâm đầu tư và cung cấp tài chính cho các dự án PPP tại Việt Nam. Cụ thể, chúng tôi muốn tập trung đóng góp ý kiến với Chính phủ về năm (5) vấn đề quan trọng dưới đây.

1. Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

1.1 Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Chúng tôi hiểu rằng các ý kiến của Nhóm Công tác Nhật Bản ngày 31/8/2020 về những trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đã phần nào được tiếp thu trong dự thảo Nghị định Hướng dẫn. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy một số ý kiến của chúng tôi chưa được tổng hợp vào dự thảo Nghị định hướng dẫn. Vui lòng tham khảo Đánh giá việc tiếp thu các ý kiến vào dự thảo Nghị định hướng dẫn đính kèm dưới đây để biết thêm chi tiết. Theo đó, chúng tôi đặc biệt nhận thấy, Dự thảo Nghị định hướng dẫn hiện nay chưa thể hiện rõ liệu trường hợp một cơ quan phía Việt Nam không phải là cơ quan ký kết hợp đồng PPP (chẳng hạn như một DNNN là đơn vị đầu mối hoặc cung cấp nhiên liệu cho dự án điện đầu tư theo hình thức BOT) bị vỡ nợ có được coi là nguyên nhân chấm dứt hợp đồng PPP trước thời hạn hay không cũng như các tác động pháp lý của việc xử lý hợp đồng kèm theo. Chúng tôi rất mong Chính phủ xem xét thêm để làm rõ những nội dung này trong Nghị định Hướng dẫn.

1.2 Thanh toán khi Chấm dứt hợp đồng

Đối với phạm vi thanh toán khi chấm dứt hợp đồng, liên quan đến phần 1.1 ở trên, chúng tôi cũng mong muốn phạm vi thanh toán bao gồm các trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, ví dụ như: i) sự kiện bất khả kháng kéo dài, ii) các cơ quan phía Việt Nam không phải là cơ quan ký kết hợp đồng PPP bị vỡ nợ, và iii) thay đổi quy định pháp luật, quy định cấp phép, ủy quyền và phê duyệt. Về phương pháp tính giá trị thanh toán khi chấm dứt hợp đồng, mặc dù Nghị định đã có những "hướng dẫn" tính toán nhưng cơ bản vẫn cho phép thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên. Chúng tôi hi vọng rằng, Chính phủ Việt Nam sẽ xử lý các vấn đề này dựa trên phương pháp thực hiện của các tổ chức tài chính và nhà đầu tư, cũng như thông lệ quốc tế trong lĩnh vực này.

2. Luật điều chỉnh

Theo Điều 27.1 tại Phụ lục IV (Quy định về hợp đồng PPP) của Nghị định hướng dẫn,

"Điều 55 Luật PPP quy định luật điều chỉnh là Luật Việt Nam. Đối với những vấn đề pháp luật Việt Nam không có quy định, các bên thỏa thuận trong hợp đồng trên cơ sở không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam". Trong khi đó, theo ý kiến của Nhóm công tác Nhật Bản ngày 31/8/2020 và Đánh giá việc tiếp thu các ý kiến, chúng tôi mong muốn Chính phủ áp dụng linh hoạt luật pháp quốc tế đối với các dự án PPP, như đã từng được áp dụng linh hoạt là luật điều chỉnh trong thời gian trước đây đối với hợp đồng BOT trong trường hợp có ý kiến bất đồng về việc áp dụng hoặc diễn giải hợp đồng BOT. Cần đảm bảo tiếp tục áp dụng linh hoạt như vậy trong thời gian tới.

3. Quyền tiếp nhận dự án

Quyền tiếp nhận dự án của bên cho vay được hiểu là quyền về cơ chế ràng buộc để bên cho vay có thể tiếp nhận dự án, khắc phục sự cố vỡ nợ và một số vấn đề khác, hoặc đôi khi thay thế nhà đầu tư (thông qua phối hợp với cơ quan ký kết hợp đồng) mà không chấm dứt hợp đồng PPP. Do các hợp đồng dự án và các quyền theo từng hợp đồng là hình thức bảo đảm cơ bản đối với các bên cho vay tài chính của dự án PPP, Luật PPP và các nghị định liên quan không nên hạn chế các quyền tiếp nhận dự án theo hợp đồng PPP.

4. Quy định chuyển tiếp

Theo khuyến nghị của chúng tôi gửi Bộ KH&ĐT vào ngày 2/10/2020, như được đính kèm tham khảo dưới đây, chúng tôi mong muốn "Những hợp đồng dự án đã được ký tắt hoặc thỏa thuận đầu tư đã ký kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không được đàm phán lại" như quy định tại Điều 76.4 (Quy định chuyển tiếp), Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, và trong Nghị định hướng dẫn thực hiện Điều 101 (Quy định chuyển tiếp) của Luật PPP. Trong khi đó, Điều 44 (Hướng dẫn quy định chuyển tiếp tại Luật PPP) trong dự thảo Nghị định Hướng dẫn không quy định các điều kiện đã nêu như đề cập trong Đánh giá việc tiếp thu các ý kiến. Do đó, chúng tôi kính đề nghị Chính phủ xem xét quy định các điều kiện tương tự trong Nghị định Hướng dẫn.

Việc bổ sung này là cần thiết, đặc biệt trong trường hợp dự án đã phát triển đến giai đoạn phê duyệt và lựa chọn nhà đầu tư, và đã thỏa thuận cơ bản về các các điều khoản, điều kiện của hợp đồng dự án giữa nhà đầu tư và Chính phủ Việt Nam (cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng, v.v.) trước ngày Luật PPP có hiệu lực. Trong trường hợp đó, nếu quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng được thực hiện sau ngày Luật PPP có hiệu lực, các điều kiện thỏa thuận đối với một nhà đầu tư có thể thay đổi rất nhiều so với thỏa thuận cơ bản, ví dụ như không được bảo đảm thực hiện hợp đồng dự án (Điều 48, Luật PPP), không quy định rõ việc bồi thường khi chấm dứt hợp đồng

dự án (Điều 52 Luật PPP), chỉ được chuyển nhượng cổ phần trong doanh nghiệp dự án cho một nhà đầu tư khác sau khi hoàn thành xây dựng (Điều 54 Luật PPP), luật điều chỉnh là luật Việt Nam (Điều 55 của Luật PPP), và bảo đảm cân đối ngoại tệ không quá 30% doanh thu dự án (Điều 81 của Luật PPP). Do đó, những thay đổi này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tính khả thi thực hiện dự án, đặc biệt nếu nhà đầu tư đang đàm phán tài chính dự án với các bên cho vay.

5. Luật biển

Trong thời gian tới, nhu cầu phát triển kho cảng tiếp nhận khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) kết hợp với nhà máy điện hoặc nhà máy điện gió ngoài khơi theo hình thức PPP được dự báo sẽ tăng lên; do đó, Chính phủ cần hướng dẫn rõ ràng việc đánh giá vùng biển mục tiêu và quyền của nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia đầu tư vào các vùng biển đó.

Bên cạnh năm (5) vấn đề đã nêu ở trên, chúng tôi cho rằng ba (3) điểm dưới đây cũng là những vấn đề chính cần quan tâm. Chúng tôi cho rằng ba (3) điểm này cần được trình bày chi tiết hơn trong một dự thảo Nghị định khác về quản lý tài chính đối với các dự án PPP do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng. Do đó, chúng tôi kính đề nghị Chính phủ xem xét những ý kiến này để cải thiện khung pháp luật về PPP, bao gồm các Nghị định và Thông tư liên quan đến PPP. Chúng tôi mong muốn tiếp tục khai thác Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản và các cơ hội khác để hoàn thiện hệ thống pháp luật về PPP của Việt Nam theo hướng hấp dẫn, khả thi và phù hợp hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài chất lượng.

- Bảo lãnh Chính phủ về cam kết thực hiện (đối với nghĩa vụ thực hiện của các cơ quan phía Việt Nam theo các hợp đồng liên quan đến dự án) / Bảo lãnh thực hiện hợp đồng;
- Đảm lãnh chuyển đổi tiền tệ và chuyển tiền; và
- Chia sẻ doanh thu.

Do Nghị định về quản lý tài chính đối với các dự án PPP do Bộ Tài chính soạn thảo vẫn chưa được xem xét, chúng tôi hy vọng rằng những đề xuất nêu trên sẽ được nghiên cứu, tiếp thu và tổng hợp vào Nghị định sắp tới.

Chúng tôi xin cảm ơn Chính phủ đã xem xét các ý kiến đề xuất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan quản lý có liên quan để đảm bảo thực hiện hiệu quả Luật PPP và luôn sẵn sàng thảo luận chi tiết với Chính phủ về các vấn đề đã nêu.

Trân trọng,

相良博英

Hirohide Sagara
Phó Trưởng ban, Ủy ban Môi trường Kinh doanh,
Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam,
Trưởng nhóm công tác 7 (Luật PPP), Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản

舩山徹

Tetsu Funayama
Trưởng Ban, Ban Diễn đàn Doanh nghiệp,
Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam,
Trưởng nhóm công tác 7 (Luật PPP), Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản

Đính kèm:

1. Đánh giá việc tiếp thu các ý kiến của Nhóm công tác Nhật Bản vào dự thảo Nghị định hướng dẫn
2. Các Công thư đề ngày 31/8/2020
3. Ý kiến góp ý liên quan đến Điều 101, Luật PPP và khoản 4, Điều 76, Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018